



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
באר שבע והדרום

תיק מס': 25/11 ב"ש

בפני כב' המפקח ש. היוזלר

התובעים: גרינולד יחיאל

הקר יצחק

ע"י ב"כ עוה"ד אמיר ע. טל

- נ ג ד -

הנתבעים: 1. בוזשוילי בנימין

2. בוזשוילי שרה

ע"י ב"כ עו"ד משה דנך

פ ס ק - ד י 1

עניינה של התביעה, בדרישת התובעים להורות על חלוקה בעין של חצר הבית המשותף המצוי בגוש 38076 חלקה 16 בבאר שבע, בין בעלי כל הדירות בבית, או למצער להורות על כי כל בעלי הדירות זכאים לעשות בה שימוש. בנוסף, במסגרת התביעה דרשו התובעים ליתן צו האוסר על הנתבעים או על מי מטעמם לבצע כל פעולת בניה ברכוש המשותף.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
באר שבע והדרום

א. העובדות הנדרשות לעניין:

1. המדובר בבית משותף בן 4 דירות, המצוי במקרקעין הידועים כגוש 38076 חלקה 16 ברחוב קלישר 11 בבאר שבע (להלן: "הבית המשותף"). את הבית המשותף סובבת חצר, המהווה, כך על פי צו הבית המשותף, רכוש משותף.
2. התובעים הינם הבעלים בדירה מס' 3, המצויה בקומה העליונה בבית המשותף. הנתבעים הינם בעלי דירה מס' 1, המצויה בקומת הקרקע של הבית המשותף. חלקם של כל אחד מבעלי הדירות ברכוש המשותף בבית, הינו 25 אחוזים.
3. המצב השורר כיום בבית המשותף הוא, שהנתבעים גידרו חלק ניכר משטח החצר הסמוך לדירתם, באופן המונע שימוש מיתר בעלי הזכויות בבית. בנוסף, בנו הנתבעים תוספות בנייה כאלה ואחרות בחצר, התקינו שערים ומנעולים בכניסות לחצר, רצפו חלק ממנה, והם נוהגים בה מנהג בעלים.
4. ביום 2.3.11 הגישו התובעים תביעה כנגד הנתבעים, במסגרתה דרשו, כאמור, להורות על חלוקה בעין של החצר המשותפת בין בעלי כל הדירות בבית, והצמדתה לבעלי הזכויות בבית המשותף. כן דרשו התובעים כי יינתן צו האוסר על הנתבעים או על מי מטעמם לבצע כל פעולת בניה ברכוש הבית המשותף, וביקשו גם כי אורה לנתבעים לשלם להם דמי איזון בגין כל בניה שבוצעה בעבר בחצר המשותפת.
5. ביום 14.8.11 הוגש כתב הגנה מטעם הנתבעים, במסגרתו טענו הנתבעים, כי ישנו הסכם עליו חתמו אלו שקדמו לתובעים, ה"ה רימר, בו הודיעו רימר כי אין להם כל זכות בחצר המגודרת, למעט מיקום מחסן עשוי עץ, וכן מיתקן להחזקת בלוני גז ודוד שמש. בנסיבות אלו דרשו הנתבעים להורות על דחיית התביעה.
6. יוער, כי תחילה הוגשה התביעה גם נגד מר אדר נפתלי, שהינו בעל דירה נוספת בבית המשותף, ואולם לבקשת התובעים נמחק מר אדר מהתביעה.
7. ביום 3.4.12 נערך ביקור במקום, ובמועדים 10.7.12, ו- 14.8.12 נשמעו עדי הצדדים. לאחר שכשלו כל המאמצים להביא את הצדדים לעמק השווה, ניתן צו להגשת סיכומים. שני הצדדים הגישו סיכומיהם בכתב.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
באר שבע והדרום

ב. טענות התובעים:

8. התובעים טוענים כי כעולה מנסח הרישום של הבית המשותף, חצר הבית הינה רכוש משותף, וממילא אין מקום לתיחומה וסגירתה על ידי הנתבעים. בתוך כך מוסיפים התובעים, כי הוכח שבמשך השנים ביצעו בעלי הדירות שימוש בשטח זה, בין היתר, לצורך החלפת בלוני גז, ואין כל ממש, כך לטענתם, בטענת הנתבעים שמדובר בשטח שהוקצה לשימושם הבלעדי.
9. התובעים מוסיפים, כי אמנם בעבר היתה במקום גדר אבנים שסבבה את החצר, ואולם היו בה שני פתחים מהם היה ניתן להיכנס לשטח הרכוש המשותף: האחד בחזית הבית הפונה לרחוב קלישר, והשני סמוך לכניסה לחדר המדרגות. לטענתם, לפני כארבע שנים בנו הנתבעים חומה חדשה, קבעו בה שער ברזל ומנעול, וסגרו גם את השער הסמוך לחדר המדרגות, ובכך סיפחו למעשה את השטח לידם.
10. בנוסף, כך טענו התובעים, הקימו הנתבעים בשטח החצר יחידת דיור חדשה, ובכך הצמידו הלכה למעשה, שלא כדין, ומבלי שקבלו את ההסכמה הדרושה לשם כך, את שטח החצר לדירתם.
11. לטענת התובעים אין ממש בטענת הנתבעים שלפיה הוסכם בינם לבין ה"ה רימר, קודמיהם בדירה, על מתן חזקה ייחודית לנתבעים בשטח החצר. בכל הנוגע לנספח ד' לכתב ההגנה - מסמך החתום על ידי בני הזוג רימר ובו הם מוותרים לכאורה על החזקה בחצר - טוענים התובעים כי אין ליתן לו משקל של ממש, משום שמר יצחק רימר, בנם של ה"ה רימר, לא זיהה את חתימת אמו על המסמך. כן מפנים התובעים לעדותו של מר יצחק רימר, בנו של מי שמכר להם את הדירה, שהבהיר כי הוריו אמנם לא עשו שימוש בחצר למעט לצורך גישה למחסן והחלפת בלוני הגז, אך בד בבד הסביר כי הם לא וויתרו על זכותם הקניינית בחצר.
12. מכל מקום, כך מדגישים התובעים, בשעה שהם רכשו את דירתם, הם הסתמכו על הרישום בפנקסי המקרקעין, ועל הצהרותיו של מי שמכר להם (מר יצחק רימר), שהבהיר כי שטח החצר מהווה רכוש משותף, וכי אין הצמדה כלשהי לדירה מסוימת. בנסיבות אלו, כך לשיטתם, אף אם היתה הסכמה של קודמיהם בדירה, אין בה כדי לחייבם. בהקשר לכך מפנים התובעים גם לעדותה של עו"ד מיכל גרינוולד, אשר ייצגה את התובעים בהליך רכישת הדירה, שהעידה כי בזמן החתימה על ההסכם נבדק נסח הרישום של הבית המשותף.
13. התובעים מסתמכים גם על עדותם של מר גרינוולד ומר יצחק הקר, שהעידו כי בעת שבדקו את הנכס הם הבחינו שהחומה הקיימת בשטח אינה מונעת כניסה לחצר משום ששני



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
באר שבע והדרום

שעריה פתוחים. בנוסף הפנו התובעים לעדותו של מר גרינוולד שהעיד כי עובר לרכישה הוא שוחח הן עם מר יצחק רימר והן עם שכן נוסף, ואף לא אחד מהם מסר להם כי ניתנה לנתבעים זכות לחזקה ייחודית בחצר.

14. בנוסף מדגישים התובעים, כי הנתבעים שינו את המצב הקיים בפועל בכך שבנו חומה חדשה הכוללת שערים ומנעולים, ואף הרחיבו את דירתם על חשבון הרכוש המשותף. מדובר, כך לטענת התובעים, בשינוי המצב בשטח, וממילא אין הנתבעים יכולים לטעון כי התובעים רכשו את דירתם בהסתמך על המצב הקיים בפועל.

15. לאור כל האמור, כך מסבירים התובעים, אין אלא לקבוע כי הם לא היו מודעים להסכמה קודמת כלשהי, ככל שהיתה, ולא יכלו לדעת עליה מהמצב ששרר בשטח. ממילא, כך לשיטתם, אף אם היתה הסכמה קודמת לחלוקת השטח אין בה כדי לחייבם. יתרה מכך, בנסיבות העניין, בהן הם רכשו את הדירה בתמורה, בתום לב, ובהסתמך על המרשם, עומדת לימינם הוראת סעיף 10 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן: "החוק").

16. לאור כל האמור סבורים התובעים, כי יש לקבוע כי שטח החצר מהווה רכוש משותף.

17. התובעים מפנים לפסיקה הענפה הקובעת כי תפיסת חזקה ייחודית אינה מהווה שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף, ולכך ששימוש כזה מותנה בהסכמת כל בעלי הדירות. לטענתם, משעה שהם לא מסכימים לכך, הרי שהנתבעים מנועים מלעשות כן.

18. התובעים מוסיפים כי אמנם נתנו בעבר את הסכמתם לכך ששוכרים מטעמם לא ישתמשו בחצר, אך זאת רק משום שבקשו להתחשב בגילו של הנתבע, ובבקשתו כי לא יתקיימו בחצר הסמוכה לדירתו מסיבות וערבי חברה. לטענתם, הנתבעים נצלו טוב ליבם זה, ניכסו לעצמם את החצר, ואף הרסו קו ביוב שבנו התובעים בשטח החצר.

19. התובעים מוסיפים כי גם בנספח ו' לכתב ההגנה – מכתב שכתב מר גרינוולד לנתבע – אין כדי להועיל לנתבעים, שכן אין במסגרתו כל וויתור על הזכות בחצר, אלא רק הסכמה לכך שצעירים השוכרים את דירת התובעים לא ישתמשו בשטח זה.

20. כן טוענים התובעים, כי הוכח שאין אמת בטענת הנתבעים שלפיה הם שילמו לה"ה רימר 13,000 ל"י בגין הזכויות בחצר. לדידם של התובעים, טענה זו נטענה בשלב מאוחר, בניגוד גמור לנטען בכתב ההגנה, וללא תימוכין כדבעי.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
באר שבע והדרום

21. התובעים מוסיפים בסיכומיהם, כי הנתבע מתנהל לאורך כל הדרך בחוסר תום לב ואף באלמנות קשה, ויש להתחשב בכך במסגרת השיקולים.

22. לאור כל האמור דרשו התובעים בסיכומיהם, כי אורה כי שטח החצר הינו רכוש משותף וכי הנתבע אינו זכאי לעשות בה שימוש ייחודי. כן בקשו התובעים, כי אגדיר את השטח המסוים שיוצמד לכל דירה ודירה מארבע הדירות, ואורה גם על תיקון צו הבית המשותף. בנוסף דרשו התובעים כי יינתן צו המונע מהנתבעים לבצע פעולות בניה בחצר.

ג. טענות הנתבעים:

23. בפתח סיכומיו מבהיר הנתבע כי הוא ורעייתו המנוחה רכשו את הדירה בשנת 1976, ועם פטירתה של רעייתו בשנת 1986, ובהיותו היורש היחיד, נותר הוא בעל הזכויות הבלעדי בדירה.

24. לגופו של עניין טוען הנתבע, כי הדירה נרכשה על ידו בשנת 1976 מה"ה בגולה. באותה עת, כך לטענת הנתבע, היו בני הזוג רימר מאיר ומרים בעלי הזכויות בדירת התובעים, והם אלו שהתגוררו בה. לטענת הנתבע, בטרם נחתם הסכם המכר בינו ובין ה"ה בגולה, התחייבו האחרונים להסדיר את הצמדת החצר לדירתו, כך שהוא יהיה רשאי לבצע בחצר שימוש ייחודי. בתוך כך, כך לטענת הנתבע, חתמו ה"ה בגולה על נספח ה' לכתב ההגנה.

25. לטענת הנתבע, ה"ה בגולה אכן הסדירו הנושא עם ה"ה רימר, ורימר חתמו על הסכמתם שלפיה החזקה בחצר תועבר לנתבע. בהקשר לכך מפנה הנתבע לנספח ד' לכתב ההגנה, ולעדויות של מר יצחק רימר, בנם של ה"ה רימר, שהעיד כי אין ספק שהחתימה שעל המסמך היא חתימתו של אביו. לטענת הנתבע, עבור הסכמתו זו הוא נדרש לשלם לה"ה רימר סך של 13,000 ל"י.

26. הנתבע מסביר, כי הסכמה זו גוברת על הרישום בפנקסים, שכן מדובר בנדבך נוסף לרישום במסגרתו הסכימו הצדדים ביניהם על חלוקה אחרת שלפיה החצר הסמוכה לנתבע תהא בחזקתו.

27. לטענת הנתבע, הסדר זה היה תקף בבית במשך למעלה משלושים וחמש שנים, כאשר במשך כל אותן שנים אף לא אחד מהשכנים, ובכלל זה ה"ה רימר, ביקשו לעשות שימוש כלשהו בחצר. הנתבע תומך יתדותיו בעניין זה גם בעדויות של מר יצחק רימר, ממנה עולה, לטענתו, כי אכן הוריו הם אלה שחתמו על ההסכמה לשימוש הנתבע, וכי חלוקה זו בשטח היתה מוסכמת



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
באר שבע והדרום

על כל בעלי הדירות. כן מפנה הנתבע לעדותו של מר יצחק רימר ממנה עלה, כי לאורך השנים היתה החצר תחומה בגדר, ומתחזקת על ידי הנתבע בלבד.

28. לטענת הנתבע, טרם רכישת הדירה על ידי התובעים הם ערכו ביקור בנכס, וראו את הגדר שהיתה במקום. יתרה מכך, כך טוען הנתבע, הוא עצמו שוחח עם התובעים והבהיר להם כי קיימת הסכמה שהחצר שייכת לו. בנסיבות אלו, כך טוען הנתבע, התובעים אינם יכולים לטעון כיום כי הם לא ידעו על ההסכמה הקיימת. גם בהקשר לכך מפנה הנתבע לעדותו של מר יצחק רימר, שהעיד כי בשלב המשא ומתן בינו לבין התובעים הוא הצביע על שטח אחר, שטח "גן הילדים", שהיה בעבר בחזקת הוריו, תוך שביחס לשטח המחלוקת ניתן היה להבין מדבריו כי הוא בשימוש הייחודי של הנתבע לאורך שנים.

29. לטענת הנתבע גם עדויות התובעים עצמם מביאות למסקנה כי הם ראו את הגדר והשערים שהוצבו במקום, והיו מודעים היטב למצב השורר ולחסימה שהוענקה, בטרם רכשו את הדירה.

30. הנתבע מפנה גם לנספח ו' לכתב התביעה, המלמד, לטענתו, על הסכמת התובעים לכך ששטח החצר לא יישמש אותם כלל, ומכאן ראייה לכך שהתובעים ידעו כי החצר אינה ברשותם.

31. לטענת הנתבע, משעה שהתובעים ידעו בעת הרכישה על כי מי שמכר להם את הדירה וויתר על הזכויות בחצר לטובת הנתבע, אין הם נהנים עוד מההגנה הקבועה בסעיף 10 לחוק המקרקעין. הנתבע מדגיש בעניין זה, כי יש לבחון את תום ליבם וידיעתם של התובעים במועד רישום העסקה, כאשר בנדון דנן, רישום המקרקעין על שם התובעים היה בשנת 2009, ואין חולק כי במקרה זה כבר ידעו התובעים על טענותיו של הנתבע, כפי שהשתקפו, לטענתו, במסמך מיום 3.2.08 (נספח ו' לכתב ההגנה).

32. מוסיף הנתבע וטוען, כי התנהלות התובעים הינה חסרת תום לב לחלוטין, הן בשל הכחשת השיחה עימו, הן לאור טענתם כי הסתמכו על המרשם בעוד שהוכח כי מר יצחק רימר ציין בפניהם את דבר החלוקה, והן נוכח הודאתם כי הם ראו את הגדר והשערים שהיו בעבר בשטח. לשיטת הנתבע, לא ייתכן כי התובעים, בהיותם אנשי עסקים, לא תמחו על קיומה של הגדר המחלקת את השטח, ולא ביררו האם קיימת הסכמה על חלוקת הרכוש המשותף.

33. הנתבע טוען גם לשיהוי מצד הנתבעים, שכן התביעה הוגשה על ידם בשנת 2011, למרות שידעו כבר בשנת 2007 על המצב בפועל.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
באר שבע והדרום

34. הנתבע אינו חולק על כי בנה בחצר יחידה נפרדת, אך הסביר כי הוא נאלץ לעשות זאת בשל התנהלות התובעים שהשכירו את דירתם לגורמים שונים, המפריעים, לטענתו, את השלווה. מכל מקום, כך לטענת הנתבע, בגין בניה זו הגישו התובעים בעבר תביעה [תיק 95/09], כאשר בסופו של דבר הגיעו הצדדים להסכמה, שקיבלה תוקף של פסק דין, המאפשרת את הותרת הבניה. הנתבע אף מדגיש, כי בכל הנוגע לבנייה שבוצעה בחצר, ואף ביחס לנושאים נוספים המפורטים בתביעה דנן, קיים השתק פלוגתא מכח פסק הדין בתיק 95/09.

35. הנתבע טוען עוד, כי אין ליתן משקל לעדות התובעים אשר טענו כי לא דיברו עם הנתבע לפני רכישת הדירה, שכן הוכח, לטענתו, כי עדותם ניתנה באופן מתחמק ומגמתי, וכי הם אנשי עסקים הבקיאים בתחום.

36. הנתבע מוסיף, כי אין לייחס לו חוסר תום לב בגין כך שלא רשם את ההסכמה הנטענת בפנקסי המקרקעין, שכן בשעה שהדבר ארע, היה הוא עולה חדש שלא היה בקי בנושאים אלו.

37. הנתבע מסכם, כי הוכח שהנושא הוכרע זה מכבר, ומכל מקום נמצא, כי הוא רכש את הזכויות בחצר בתמורה ובתום לב, וכי התובעים ידעו או היו אמורים לדעת על כך. ממילא, כך לשיטת הנתבע, אין אלא לקבוע כי זכותו בחצר גוברת על זכות התובעים, וכל קביעה אחרת, כך לטענתו, תעמוד בסתירה להגינות המתחייבת ולזכותו המוגנת לקניין.

ד. דיון הכרעה:

38. בטרם אכנס לגופם של דברים אבקש לתחום את גבולות המחלוקת הנתונה להכרעתי, וזאת מאחר שמחד גיסא נכללו בכתב התביעה סעדים שונים שאינם מצויים במסגרת סמכותי העניינית, ומאידך גיסא סעדים אחרים שלכאורה מצויים בסמכותי לא נתבעו בכתב התביעה או נזנחו בשלב מאוחר יותר, בתצהירים ובסיכומים.

39. בכתב התביעה דרשו התובעים, כי אורה על חלוקת הרכוש המשותף באופן שלכל אחד מהצדדים יוקצה שטח מסוים בחצר. מהותה של דרישה זו, הינה, למעשה, דרישה לפירוק השיתוף והצהרה על בעלות של כל אחד מהצדדים בשטח מסוים ברכוש המשותף.

40. סמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין, כך על פי סעיף 72(ב) לחוק, הינה לדון בתובענות לסילוק יד בלבד, והיא אינה משתרעת על תביעה לבעלות או לפירוק שיתוף. בהינתן



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
באר שבע והדרום

זאת, הרי שאין לי אלא לסלק נושא זה על הסף. מאחר שלא הוברר עד תום מה בדיוק מבקשים התובעים בעניין זה, לא מצאתי לנכון להעביר נושאים אלו לבית המשפט המוסמך, ולמותר לציין כי אין בהחלטה זו לסילוק על הסף, כדי להוות מעשה בית דין בעניינים אלו.

41. נושא נוסף שעלה בכתב התביעה, ונזנח בסופו של דבר על ידי התובעים בסיכומיהם, הוא דרישת התובעים לקבלת דמי איזון בגין בניה שבוצעה בעבר. מאחר שהתובעים זנחו נושא זה, ואף לא הביאו כל ראיה ביחס לכך במסגרת ההליך, אין לי אלא לדחות תביעתם לדמי איזון.

42. בכתב תביעתם ובסיכומיהם, התייחסו התובעים גם לבניה עתידית שלטענתם מתעתד הנתבע לבצע בחצר, ודרשו כי יינתן צו האוסר על הנתבעים לבצע בניה עתידית. בד בבד, לא דרשו התובעים סעד של פינוי והריסה כנגד מה שכבר היה בנוי בשטח בעת הגשת התביעה. דא עקא, שהתובעים לא הבהירו, לא בתחילת ההליך ולא לאורכו, מה היה המצב בפועל בעת הגשת התביעה, וממילא לא ניתן לקבוע ממצא עובדתי בעניין זה בפסק הדין. בנסיבות אלו, ונוכח העובדה שכאמור לא דרשו התובעים סעד כנגד הבינוי שכבר קיים בפועל, לא יינתן סעד שכזה, ואולם מובהר בזאת, כי אי מתן הסעד נוגע רק לבינוי שהיה קיים בעת הגשת התביעה. בכל הנוגע לבינוי שבוצע לאחר מכן, יחולו הכללים כפי שיובהרו בפסק הדין להלן, וככל שהצדדים ימצאו לנכון, הם יהיו רשאים כמובן לפנות בהליך מתאים לבירור נושאים אלו.

43. המחלוקות שעלי לעסוק בהן אפוא הן, האם יש להיעתר לדרישת התובעים להורות על פתיחת השערים שהציב הנתבע בחצר הסמוכה לדירתו, האם יש להיעתר לדרישת התובעים ליתן צו הקובע כי הנתבע אינו רשאי לבצע בשטח זה שימוש ייחודי, והאם ניתן לאסור על הנתבע לבצע בניה בשטח זה.

44. והנה, בחלק ניכר מהמחלוקות הללו עסקה התביעה שהגישו התובעים בתיק מפקח 95/09, **יחיאל גרינוולד ואח' נ' בנימין בוזשווילי**. בסעיף 5 לכתב התביעה מושא התיק הנ"ל, טענו התובעים כי: **"הנתבע בניגוד לדין השתלט על החצר המשותפת...גידר אותה ואף בנה בחצר המשותפת מחסן מפה. לפני מס' חודשים הנתבע התקין מנעול על שער החצר ואינו מתיר כניסה לחצר המשותפת אפילו לא למחלקי הגז שבאים להחליף בלוני גז, התובע מונע מבעלי הדירות שימוש בחצר המשותפת כאילו הייתה רכושו הבלעדי"**. בהמשך, בסעיף 6 לתביעה הנ"ל, דרשו התובעים כי: **"לפיכך, מתבקש כב' המפקח להורות על הריסת הגדר ועל הריסת המחסן ולאסור על הנתבע מלהפריע לבעלי הדירות מלעשות שימוש סביר בחצר המשותפת"**.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
באר שבע והדרום

45. בסופו של יום, הגיעו הצדדים לכלל הסכמה, אשר קיבלה תוקף של פסק דין, במסגרתה נקבע, בין היתר, כי לשוכרת מטעם התובעים יותר שימוש בחצר רק למשך חג הסוכות, וכי: "גב' מרסל תתאם עם גב' בוזשווילי, את המועד להחלפת בלוני הגז, גב' בוזשווילי תוודא שבמועד שיגיע הטכנאי יהיה השער פתוח. לגב' מרזל יותר לפחות פעם ביום להיכנס לחצר ולאסוף חפצים שנפלו..."

46. בהינתן זאת, ברי כי בראשית דיוננו יש לבחון האם קיים "השתק עילה", מכח פסק הדין בתיק 95/09 הנ"ל. להווי ידוע, כי "המונח 'השתק עילה' נגזר ממונח רחב יותר, הוא המונח 'מעשה-בית-דין'...מקום שתביעה נידונה לגופה והוכרעה על-ידי בית-משפט מוסמך, שוב אסור להיזקק לתביעה נוספת בין אותם הצדדים או חליפיהם, אם זו מבוססת על עילה זהה". [ר': א. גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, 86]. נפסק גם, כי הכלל בדבר השתק עילה חל בין אם מדובר בפסק דין שיש בו הכרעה במחלוקת שבין הצדדים, ובין אם מדובר בפסק דין שנתן תוקף להסכמתם. כך סוכמה ההלכה בנושא על ידי בית המשפט העליון בע"א 1545/08 אברהם מוסקונה נ' סולל בונה בע"מ (פורסם באתר נבו):

"הכלל בדבר מעשה בית דין, ככל שהוא נוגע להשתק עילה, קובע כי אם תביעה נדונה לגופה והוכרעה על-ידי בית משפט מוסמך – בית המשפט לא ייזקק לתביעה נוספת בין אותם הצדדים או חליפיהם אם היא מבוססת על עילה זהה (ראו: ע"א 823/08 חזן נ' רשות המסים – פקיד שומה נתניה, פסקה 7 ([פורסם בנבו], 4.1.2009) (להלן: עניין חזן); נינה זלצמן מעשה-בית-דין בהליך אזרחי 29-30 (1991) (להלן: זלצמן)). כאשר צד להליך מעלה טענה בדבר השתק עילה בשל עילות תביעה זהות, המבחן לו נזקק בית המשפט חורג מן הבחינה הפרטנית של שני כתבי התביעה זה מול זה. הוא בוחן האם על-פי מהות הדברים מדובר בשתי התדיינויות הנוגעות לאותו עניין עצמו והאם הזכות או האינטרס המוגן שנפגעו בשתי התביעות זהים. כמו כן בוחן בית המשפט את מידת הדמיון בתשתית העובדתית הניצבת ביסוד שני ההליכים. (ראו: ע"א 1650/00 זיסר נ' משרד הבינוי והשיכון, פ"ד נז(5) 166, 181 (2003) (להלן: עניין זיסר); עניין חזן, פסקה 7; אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי 112-114 (מהדורה עשירית, 2009) (להלן: גורן)). עוד נפסק כי מקום שהתובע יכול היה לרכז את כל העובדות ואת כל הטענות הנוגעות למעשה במסגרת ההתדיינות הראשונה, תיחשבה שתי התובעות כנסמכות על עילות זהות (ראו: עניין זיסר, 181; ע"א 2035/03 לב יסמין בע"מ נ' ת.ג.י. בע"מ, פ"ד נח(6) 447, 453 (2004); עניין חזן, פסקה 7; גורן, 113). ודוק: אין צורך שההליך הראשון יכלול את כל המרכיבים



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
באר שבע והדרום

הנכללים בהליך הנוסף וכדברי השופטת א' פרוקצ'יה: מבחן "זהות העילות" בהקשר של עקרון מעשה-בית-דין זכה לפירוש רחב למדי בפסיקת בתי-המשפט. הוא מתקיים מקום ששתי התביעות מבוססות על עילות זהות בבסיסן, גם אם בתביעה המאוחרת נכללים פרטים ומרכיבים נוספים שלא פורטו בתביעה הקודמת (עניין זיסר, 181). ויטעם – לצורך החלתו של הכלל בדבר השתק עילה, אחת היא אם מדובר בפסק-דין הנותן תוקף להסכמה שהושגה בין בעלי הדין או בפסק-דין שיש בו הכרעה במחלוקות שבין הצדדים לאחר ניהול ההליך בפני הערכאה המבררת (ראו זלצמן, 330)". (ההדגשות לא במקור).

47. לדברים אלו השלכה ברורה על ענייננו. כמובא לעיל, הנושא שעמד לדיון בתיק 95/09 היה, בין היתר, טענת התובעים להשתלטות הנתבע על שטח החצר, על בניית החומה הסובבת את החצר, ועל נעילת השערים בחומה זו.

48. אמנם, במקרה דנן מדובר על גדר חדשה שנבנתה במקום הגדר הישנה, ואולם אין מדובר בגדר השונה מהותית מהגדר הקודמת, ולפיכך, הלכה למעשה, מהותן של שתי העילות, זו שבתביעה 95/09 וזו של התביעה דנן, אחת היא.

49. נמצא, כי בנושאים שבהם עסקה התביעה בתיק 95/09, ובכלל זה הגדרות הסובבות את החצר, השימוש הייחודי המבוצע על ידי הנתבע, ופתיחת השערים, קיים מעשה בית דין מכח פסק הדין בתיק 95/09, והוא מחייב את הצדדים.

50. פועל יוצא של האמור הוא שיש לדחות את דרישת התובעים להורות על הפסקת השימוש הייחודי של הנתבע בחצר, בכפוף לתנאים שנקבעו בפסק הדין הנ"ל, קרי, פתיחת השערים לצורך החלפת בלוני גז, ומתן אפשרות של פעם ביום להיכנס לחצר לצורך איסוף חפצים שנפלו. כן יש לדחות את טענות התובעים ביחס לגדרות עצמן.

51. בדברים אלו ניתן היה לסיים את הדיון בכל הנוגע לעילות מושא התביעה הקודמת שחזרו על עצמן בהליך זה. יחד עם זאת, בבחינת מעבר לדרוש, ומאחר שבסופו של דבר התביעה נידונה בפניי גם לגופה, מוצא אני לנכון להוסיף, כי סבורני שיש לדחות התביעה גם לגופו של עניין, בכל הנוגע לשימוש הייחודי של הנתבע בחצר ופתיחת השערים.

52. כפי שפורט לעיל, אין מחלוקת בין בעלי הדין ביחס להגדרת שטח כלשהו בבית המשותף - כל הצדדים תמימי דעים על כי שטחי החצר רשומים כרכוש משותף. עניינה של המחלוקת, בשאלה האם בפועל, למרות היות השטח "רכוש משותף", הוענקה לנתבע זכות לחזקה ייחודית בשטח זה, והאם זכותו זו, ככל שהוענקה, רלוונטית גם ביחסיו מול התובעים.



מישרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
באר שבע והדרום

53. סעיף 55(ג) לחוק, הוא הסעיף העוסק באופן הצמדת חלקים מהרכוש המשותף לדירה פלונית, וקובע: "בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון, כמשמעותו בסימן ג' לפרק זה (להלן - התקנון), שחלק מסוים של הרכוש המשותף יהיה צמוד לדירה פלונית, ובלבד שלא יקבעו זאת ביחס לחדרי מדרגות, מעליות, מקלטים ומיתקנים המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות; הוצמד חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית, לא יחולו עליו הוראות פרק זה בנוגע לרכוש המשותף, ודינו לכל דבר כדין הדירה שאליה הוצמד".
54. בד בבד, קובע סעיף 62 לחוק: "בעלי הדירות רשאים לערוך תקנון ולשנות את הוראותיו ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, אולם אין לקבוע או לשנות בתקנון זכויות של בעלי דירות או להטיל עליהם חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק זה אלא בהסכמתם, ואין לקבוע הצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות" (ההדגשה לא במקור). בנוסף, סעיף 12 לתקנון המצוי קובע כי: "החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או שיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, או בתקנון זה, או המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה".
55. מסעיפי החוק הנ"ל עולה, כי לא ניתן להצמיד חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה מסוימת מבלי שהסכימו לכך כל הדיירים.
56. חריג לכלל הנ"ל נקבע בסעיף 71ב לחוק, אשר חוקק בתיקון מס' 18 לחוק, במסגרתו ביקש המחוקק להקל על בעלי דירות בבית משותף להרחיב דירתם תוך ניצול אחוזי הבניה הקיימים בדין, ולמנוע מצב בו מיעוט מצומצם יחסום אותם מלעשות כן (ר': א. אייזנשטיין, יסודות וחלכות בדיני מקרקעין, חלק שלישי, 211; כן ר': דברי הכנסת, כרך 133, עמוד 1797). סעיף זה קובע כי לצורך בנייה שמטרתה הרחבת דירה, ניתן להסתפק ברוב מיוחד של מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם.
57. אלו הם פני הדברים ביחס להצמדת חלק מסוים ברכוש המשותף לדירה ספציפית. והנה, לא פעם נקבע, כי תפיסת חזקה ייחודית ברכוש המשותף, אף ללא שבוצעה הצמדה במרשם, דומה במהותה להצמדה, שכן בשני המקרים תגרום הפעולה לגריעה מהזכויות שיש לדיירים האחרים ברכוש המשותף. כך הסביר זאת בית המשפט העליון בע"א 2525/92 גבי וקרני ראובברג נ' עיריית רמת גן, פ"ד, מז(5), 850: "...משמעות הדברים היא, כי לכל אחד מבעלי הדירות זכות להתנגד לפגיעה ברכוש המשותף על ידי בנייה בו וצירופו לאחת הדירות. תפיסת חזקה בלעדית על ידי בנייה ב'רכוש המשותף', המיועד לשמש את כל 'בעלי הדירות', שוללת לצמיתות את זכות השימוש באותו חלק מ'הרכוש המשותף' משאר 'בעלי הדירות', וברור כי דבר כזה אינו יכול להיעשות אלא בהסכמתם..." (ר' עוד רע"א 698/85).



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
באר שבע והדרום

בן צור ואח' נ' נעים ששון ואח', תק-על 87(2), 732; י. ויסמן, דיני קניין בעלות ושיתוף (תשנ"ז-1997 עמ' 454-455).

58. מכאן, שככלל, בדומה לבעל דירה המבקש להצמיד לדירתו חלק מהרכוש המשותף, גם בעל דירה המבקש לעצמו זכות לחזקה ושימוש ייחודי ברכוש המשותף, נדרש להציג הסכמה מטעם כל בעלי הדירות, זולת החרג שבסעיף 271 לחוק.

59. ומה אופן הענקת ההסכמה האמורה? נקבע, כי הסכמה זו של בעלי הדירות, בין אם לשם מתן זכות קניינית, ועל אחת כמה וכמה כאשר מדובר בהסכמה למתן זכות לשימוש ייחודי במקרקעין, אינה חייבת להינתן במסגרת הסכם בכתב. לא פעם נפסק, כי גם הסכמה בעל-פה, הסכמה היא. כך הבהיר זאת בית המשפט העליון בע"א 815/81 כליפא נ' שאול, פ"ד (ל) 3, 78:

"...הסכמתם של המשיבים ניתנה בעל-פה. בע"א 188/76 [1] הנ"ל, בעמ' 384-385, הוחלט, שהסכמה בין בעלי דירות בבית משותף לשימוש ייחודי ברכוש המשותף על-ידי אחד מהם אינה עיסקה במקרקעין, הטעונה מסמך בכתב לפי סעיף 8 של החוק...הסעיף אינו אומר, שהסכמה שלא ניתנה בכתב חסרה תוקף. הדגש שבו הוא על הרחבת ההסכמה, שהסכימו בעלי הדירות בהווה, והחלתה גם על כל מי שירכוש בעתיד דירה מן הדירות שבבית. הרחבה כזאת תיתכן, רק אם ההסכמה ניתנה בצורת החלטה, שנרשמה בספר הפרוטוקולים של האסיפה הכללית, ולשם כך גם מעניק סעיף 71 את זכות העיון בספר הפרוטוקולים לכל אחד מבעלי הדירות בבית המשותף, אבל לגבי אותם בעלים, שהם עצמם הסכימו לשימוש ברכוש המשותף על-ידי אחד מהם, כמו במקרה דנן, אין הסעיף 71 דורש רישום בכתב או ראיה כלשהי בכתב. מובן מאליו, שהסכמה בעל-פה חייבת להיות מוכחת בראיות מספיקות. אם היא מוכחת כך, אין כל חשש לאי-ודאות...אין לראות טעם, מדוע נכונות זו של המחוקק לתת תוקף להסכמה בעל-פה לא תחול גם על הסכמת בעלי הדירות בבית משותף לטובת אחד מהם. ואמנם, כך הוחלט בע"א 188/76 [1], ואין לנו לסטות ממה שנפסק שם."

60. יתרה מכך, נקבע כי הסכמה שכזו, בין אם הוענקה בכתב ובין אם הוענקה על פה, תחייב צדדים שלישיים, ככל שאלה ידעו או היה עליהם לדעת על קיומה, וזאת, גם אם הדבר לא נרשם בתקנון הבית המשותף או בספר הפרוטוקולים. יפים לעניין זה דברי בית המשפט המחוזי בע"א (מחוזי - ת"א) 1020/03 בובליל ישראל נ' שטיינר יוסף (פורסם באתר נבו 25.2.04), שסיכם את ההלכה כדלהלן:

"...העדר הרישום לפי הוראות חוק המקרקעין תשכ"ט - 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") אין בו כדי לשלול מהצדדים לפעול לפי הוראות ההסכמים נשוא התביעה והן מחייבות את הצדדים וחליפיהם...בסעיף 71(א) לחוק המקרקעין נקבע כי: "החלטה של בעלי הדירות שנתקבלה בהתאם לתקנון ונרשמה בספר ההחלטות תחייב כל בעל דירה, בין שהיה בעל דירה בשעת קבלת ההחלטה ובין שהיה לבעל דירה אחרי קבלתה; ספר ההחלטות יהיה פתוח



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
באר שבע והדרום

לעיון בכל עת סבירה לכל בעל דירה". לעמדת רישומו של הסכם הורתו ותכליתו ראייתית הן כלפי הבעלים הן כלפי צדדים שלישיים. המשמעות שלכך היא שבמקרה בו גלוי וידוע היה כל העת לצדדים דבר קיום ההסכם, ורישומיו נכרו היטב עקב הבינוי והנוהג בשטח מזה עשרות בשנים, לא קם צורך ראייתי נוסף ובפרט שהצדדים שניהם אינם מכחישים עצם קיום ההסכם וכל מחלוקתם מיוחסת לנפקותה המשפטית של מציאות נהגת מוסכמת מקום בו לא נתבצע רישום בלשכת רישום המקרקעין. יש להעדיף את הפירוש התכליתי על זה העולה מן הלשון הפורמלית של סעיף 29א' לחוק המקרקעין. על תכלית הרישום בסעיף 29א' עמד השופט ח' כהן בע"א 269/74 מנחם בוקובזה נ' הממונה על המרשם בקובעו כי "פעולתו של הרישום היא השגתה והבטחתה של הפומביות: "רישומו של הסכם-שיתוף מבטיח שכל אדם יידע, או יועמד בחזקת יודע, כיצד מתנהלים המקרקעין המשותפים הנדונים בו, וכיצד נחלקו השותפים בינם לבין עצמם בזכויותיהם ובחובותיהם בכל הנוגע למקרקעיהם המשותפים". (פ"ד כט(1), 243, עמ' 251-250). פומביות הרישום, אם כן, היא העומדת ביסוד הרישום ולאורה יש לבחון אף יחסי חליפי הצדדים להסכם ועל אף שאינם צדדים להסכם גופא. אין דומה מצב בו צד קנה בתום לב נכס ובלא ידיעה על הסכמים בין בעליו הקודמים לצד ג', למציאות בה ידע הקונה על ההסכמים, וראה תוצאותיהם בשטח. גישה זו ביחס לבתים משותפים מקובלת אף על פרופסור י. ויסמן בספרו "דיני קניין": "גם בעלי גישה המכבדת את הדרישות הפורמליות שבדיני בתים משותפים יכירו בכך שהמשפט מספק כלים שבעזרתם ניתן לרכך תוצאות בלתי רצויות העלולות להיגרם עקב יישום קפדני של ההוראות הפורמליות שבחוק". (ויסמן יהושע, "דיני קניין", המכון למחקרי חקיקה ומשפט, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית, ירושלים. תשנ"ז-1997. עמ' 445)". (ההדגשה לא במקור).

61. על רקע ההלכות הללו נבחן את המקרה דנן.
62. לאחר שבחנתי את חומר הראיות ועדויות הצדדים, אין לי ספק כי בין הנתבע לבין ה"ה רימר, נכרת הסכם, במסגרתו הסכימו ה"ה רימר שהחזקה הייחודית בחצר תהא בידי הנתבע, בכפוף להותרת מספר מתקנים בשטח ומתן אפשרות גישה אליהם, וזאת בתמורה לקבלת סכום של 13,000 ל"י.
63. בראש ובראשונה מבוססת מסקנתי זו על נספח ד' לכתב ההגנה, מסמך מיום 3.8.76, בו נכתב כדלקמן:

"הננו מאשרים בזה כי בחצרם של הדרה וניסן בגולה הגרים ברחוב קלישר מס' 11/1 באר שבע, מצויים הפריטים הבאים השייכים לנו: 1. מחסן עשוי עץ הנמצא בפינת החצר בגודל של 2.50 מ' X 2.10 מ'. 2. מתקן להחזקת בלוני גז הנמצא ביציאה מהמטבח לחצר. 3. דוד השמש העומד על 4 עמודי ברזל הנמצא ביציאה מהמטבח לחצר. פרט לגישה אל הפריטים הנ"ל אין לנו כל חזקה על החצר של הח' הדרה וניסן בגולה".



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
באר שבע והדרום

64. על המסמך הנ"ל מצויות חתימות של מר רימר מאיר וגב' רימר מרים, כאשר בעדותו אישר מר יצחק רימר, בנם של ה"ה רימר כי: "...לגבי המסמך הוא מסמך שחתום ע"י אבי ב-100%. במסמך הם מאשרים שאין להם חזקה בחצר, זה שונה ממה שאמרתי, אני דיברתי על שימוש. אבא היה צלול עד יומו האחרון." (ר' עמוד 11 שורות 257-258 לפרוטוקול).

65. גם עדותו של הנתבע בעניין זה היתה אמינה עלי עד מאוד. במסגרת עדותו זו העיד הנתבע, כי: "...קניתי מבגולה כולל גינה. בגולה הבטיחו לי שהגינה שלי ואנחנו נסדר מול רימר, עד שרימר לא חתמו לי לא שלמתי. הם קיבלו 13 אלף וחתמו" (עמוד 6 שורות 115-117 לפרוטוקול). כך העיד מר בוזשווילי גם בהמשך (שם שורות 132-130): "...קניתי בית עם גינה. אמרתי תגמרו בקשר לגינה שלא יהיו בעיות. ואז רימר ובגולה סיכמו ביניהם ש13 אלף לירות ילכו לרימר".

66. זאת ועוד: המצב ששרר בפועל במשך למעלה משלושה עשורים, בהם לא נשמעה טענה מצד מי מהשכנים, תומך אף הוא בעמדת הנתבע. כך תיאר זאת מר רימר בעדותו בפניי (שם עמוד 11 שורות 239-241): "למעט מחסן שהיה להוריי בקצה הבניין מאחור ובלוני הגז, הוריי לא השתמשו בחצר הימנית...". ובהמשך (עמוד 12 שורות 270-273) העיד כי: "ההורים שלי מעולם לא הרגישו צורך להילחם במישהו, הפקיעו להם וזה היה גורלם, זה היה של בגולה וכך זה נשאר. כשאני אומר את זה, אני מצייר את הבניין מה שאני מסמן בוורוד את השביל גישה לחצר האחורית, השטח שאני צובע בוורוד היה שייך לקומות העליונות, זה השטח שהפקיעו, כל ייתרת השטח שלא צבעתי שייכת לדירות מתחת...".

67. מן המקובץ עולה, כי הוכח ברמת ההוכחה הנדרשת, כי אכן ה"ה רימר, בתמורה לתשלום של 13,000 ל"י, העניקו לנתבע את הסכמתם המפורשת לחזקה ייחודית בחצר, בכפוף למתן מעבר לבלוני הגז ולמחסן המוצב בשטח.

68. משעה שזו היא מסקנתי, עלי להידרש לשאלה, האם הסכמה מפורשת זו מחייבת את התובעים כמי שבאים בנעלי ה"ה רימר, או שמא לאו. כמובא לעיל, ככל שהתובעים ידעו על הסכמה זו או שהיה עליהם לדעת עליה, הרי שהיא מחייבתם.

69. והנה, במסגרת העדויות שנשמעו בפניי, הוכח למעלה מכל ספק כי בשעה שבאו התובעים לרכוש את דירתם, כבר היתה בשטח חומה גבוהה הסובבת את כל החצר (ר' מוצג ת/1). אמנם, כאמור, מדובר היה בחומה העשויה בלוקים, וגובהה היה נמוך מעט מזו הקיימת כיום, אך אין ספק כי חומה זו תחמה באופן מוחלט את החצר לדירת הנתבע. מר גרינוולד בעצמו



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
באר שבע והדרום

העיד על כך כדלהלן: "החומה סגרה משני הצדדים למעט השער, היא היתה נמוכה יותר" (עמוד 4 שורה 106). כך גם העיד מר הקר (עמוד 2 שורות 33-34) "אני מאשר הייתה במועד המכירה חומה נמוכה הן בשביל וכן במדרכה בגובה של כמטר ו 30 היה גם שער".

70. הוכח גם כי התובעים, אנשי עסקים המה, שרכישת דירות אינה זרה להם. כך העיד על עצמו מר גרינוולד (עמוד 3 שורה 74): "עשיתי כל מיני עסקאות נדל"ן", ומר הקר הוסיף כי: "יש לי דירות נוספות אני שותף עם גיסי" (עמוד 1 שורה 18 לפרוטוקול). מר הקר אף העיד כי: "אני ראיתי את הדירה לפני שקניתי אני רואה את כל הדירות לפני שאני קונה".

71. לאמור, מדובר בתובעים שהינם בעלי ידע ממשי ברכישת נדל"ן, אשר ראו בזמן אמת כי החצר תחומה בחומות מכל צדדיה, באופן שהנתבע הוא שנהנה ממנה. היה על התובעים להבין אפוא, מהמצב ששרר בשטח, על כי קיימת, או למצער, נטען כי קיימת, הסכמה על חלוקת החצר, הסכמה, המהווה נדבך נוסף על הרישום בפנקסי המקרקעין. דא עקא, שהתובעים בחרו לעצום את עיניהם ולהתעלם מכך.

72. יתרה מכך: בסעיף 9 לתצהירו העיד הנתבע, כי הוא פגש את התובע מס' 1 בטרם הלה רכש את הדירה, והבהיר לו "באופן שאינו משתמע ל- 2 פנים, כי כל החצר הינה בבעלותי ובשימושי הבלעדי בלבד, כאשר ציינתי כי זכות בלעדית זו הנה מהמועד רכשתי ממשפחת בגולה את הדירה והקרקע ובהסכמת רימר". את עדותו זו של הנתבע לא הצליחו התובעים להכחיש במסגרת חקירתו הנגדית של הנתבע, וגם בכך הוכחה כנגד גרסתם שלפיה לא ידעו על ההסכמה הנוהגת בשטח.

73. אם לא די בכל אלה, הרי שאף התנהלות התובעים מאוחר יותר מחזקת את המסקנה כי הם ידעו על החלוקה הנטענת. התובעים העידו כי בשלב מסוים הם בקשו להקים קו בויב נוסף לדירתם, ולצורך כך ביקשו את הסכמת התובע. אין זה מתקבל על הדעת שהתובעים היו פועלים בדרך זו, לו סברו שפעולות הנתבע מהוות השתלטות שלא כדין על רכוש משותף.

74. מכל המקובץ אין לי אלא להסיק, כי בעת רכישת הדירה על ידי התובעים הם היו מודעים היטב לגדרות הסובבות את החצר, והם ידעו, או לכל הפחות היו אמורים לדעת, על כי קיימת הסכמה בין קודמיהם לבין הנתבע לשימוש הייחודי של הנתבע בשטח החצר.

75. לאור זאת, ונוכח ההלכות המובאות לעיל, אין לי אלא לקבוע כי הסכמה זו מחייבת אותם, ונמצא כי אף לגופו של עניין יש לדחות את דרישת התובעים לסילוק ידו של הנתבע מהחצר.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
באר שבע והדרום

76. בכך לא תם דיונינו. הדברים האמורים נוגעים לעצם השימוש הייחודי של הנתבע בחצר ולגדרות הסובבות אותו. עם זאת, שונים הם פני הדברים לחלוטין, בכל הנוגע לביצוע פעולות בנייה בחצר על ידי הנתבע, ובכלל זה פעולות שונות שהוא ביצע או מתעתד לבצע לצורך הרחבת דירתו.

77. בניה ברכוש המשותף, ואף על הצמדה, הינה פעולה אשר מעצם טבעה דורשת ניצול של "זכויות בניה". "זכויות בניה" אינן חלק מהרכוש המשותף כהגדרתו בחוק, אלא מהוות נכס כלכלי רב ערך המצוי בבעלות משותפת של כלל בעלי הדירות בבית המשותף. כך סיכם זאת בית המשפט העליון בע"א 11965/05 עזבון המנוח מרדכי קליין נ' דוד שרון, פרופסור, תק-על 3111, (3)2009:

"...הפסיקה קבעה, כי אחוזי בניה הם נכס משותף, אך הם אינם 'רכוש משותף'...חרף העובדה לפיה 'אחוזי בניה' או 'זכויות בניה' אינם מהווים חלק מהרכוש המשותף נקבע כי מדובר בנכס בעל ערך כלכלי (ראו עניין ביבי לעיל, בעמ' 501; עניין גלמן לעיל, בעמ' 393) הנמצא בבעלות משותפת של הדיירים בבית המשותף וכפי שציין הנשיא שמגר: 'זכויות הבניה הינן נכס בבעלות משותפת, אף-על-פי שאינו חלק מן הרכוש המשותף. הזכויות הללו נובעות מהבעלות בקרקע, וכיוון שהקרקע עליה ניצב בית משותף שייכת במשותף לדיירים, אף זכויות הבניה עליה שייכות להם במשותף...' (עניין מזרחי לעיל, בעמ' 680; וראו גם עניין גלמן לעיל, בעמ' 393). ...מדובר בנכס הנמצא בבעלות משותפת של בעלי הדירות בבית המשותף..." (הדגשה לא במקור).

78. בהינתן העובדה שזכויות הבניה הינן בבעלות משותפת של כלל בעלי הדירות, נקבעה ההלכה שלפיה לא יתא רשאי בעל דירה לבצע פעולות בניה על השטח שהוצמד לו, אלא אם הותר הדבר, מפורשות, בתקנון הבית המשותף [ר' למשל: ע"א 5043/96 גלמן נ' הררי, פ"ד נד(3), 389].

79. זאת ועוד: היות שזכויות הבניה הינן נכס בבעלות משותפת, הבעלות של בעלי הדירות מתפשטת בכולן, ואין שותף רשאי לנצל אף את חלקו היחסי בשטח מסוים. כך הבהיר זאת פרופ' דויטש [מ. דויטש, קניין, כרך א', 694-693]:

"הנקודה עתה היא, שאף אם הבניה נעשית בחלק פתוח שהוצמד לדירה נתונה, הרי שאחוזי בניה הם נכס אחר כשלעצמו – נכס מופשט משותף – ואין שותף יכול ליטול לעצמו זכויות ייחודיות בנכס המשותף, ללא הסכמת האחרים. כך, במספר מקרים נפסק, כי הצמדה של הגג בתקנון, לבעל דירה נתונה, אינה כורכת עימה באופן אינהרנטי גם העברה אליו של אחוזי הבניה המתאימים" (ההדגשה לא במקור).



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
באר שבע והדרום

80. באופן דומה נקבע גם בפסק הדין ברע"א 11017/08 נתן פל נ' מרדכי ליבוביץ, תק-על 2010(3), 2320 (להלן: "פס"ד פל"):

"ברגיל, הצמדה של שטח לדירה מקנה לבעל הדירה זכות בעלות בשטח המוצמד אך אינה מקנה לו זכות לבנות על השטח המוצמד, וניצול זכויות הבנייה בבית המשותף מותנה אפוא בהסכמת יתר בעלי הדירות... ובקיצור, גריעה של חלק מהרכוש המשותף והצמדתו לדירה מסוימת אין פירושה שיוך של אחוזי הבניה לאותה דירה (ההדגשות לא במקור).

81. נמצאנו למדים, כי זכויות הבניה שייכות לכל בעלי הדירות במשותף, ולפיכך, באופן עקרוני, לצורך פעולה של ייחוד זכויות הבניה לדירה מסוימת, דרושה הסכמת כל בעלי הדירות, וזאת גם מקום בו הבניה אמורה להתבצע על שטח הצמוד לדירה מסוימת.

82. כמובא לעיל, במסגרת תיקון מס' 18 לחוק, משנת 1995, ביקש המחוקק להקל על בעלי דירות בבית משותף להרחיב דירתם תוך ניצול אחוזי הבניה הקיימים בדין, ולמנוע מצב בו מיעוט מצומצם יחסום אותם מלעשות כן. בתוך כך, חוקק סעיף 71 לחוק, אשר קבע כי ניתן להסתפק ברוב מיוחד של מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסוימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה. לאמור, כאשר מדובר על הרחבת דירה אין עוד צורך בהסכמת כל בעלי הדירות לשם חלוקת זכויות הבניה, וניתן להסתפק ברוב שנקבע בסעיף. ככל שמדובר בבניה שמטרתה בניית ממ"ד, דרוש אף רוב של 60 אחוזים בלבד.

83. עינינו הרואות, כי עצם ניצול זכויות הבניה וחלוקתן מחייבת את הסכמת בעלי הדירות, או במקרה של הרחבת דירה, הסכמת הרוב הנקוב בסעיף 71 לחוק, וזאת גם אם השטח עצמו הוצמד לדירה מסוימת. על אחת כמה וכמה מקום בו מדובר במתן זכות שימוש ייחודית בשטח, שלא נרשמה בתקנון הבית המשותף.

84. מסקנת הדברים היא, שעל אף קביעתי לעיל שלפיה הוכח, כי התובעים מחויבים להסכמת קודמיהם למתן זכות שימוש ייחודית לנתבע בחצר, אין הנתבע רשאי לבצע בניה בחצר זו, ללא שקיבל את הסכמת הרוב הדרוש.

85. כמובא לעיל, במסגרת תביעה זו לא ביקשו התובעים סעד של הריסה (אף לא ביחס לגדרות), כי אם מתן צו האוסר על הנתבע לבצע בניה. כמו כן, כאמור, לא הוברר במסגרת הדיון מה המצב העובדתי בפועל בעת הגשת תביעה זו ובעת הגשת התביעה הקודמת. בנסיבות אלו, לא נותר לי אלא לקבוע כי צודקים התובעים בטענתם שלפיה הנתבע אינו רשאי לבצע בניה בשטח החצר מבלי להציג את הסכמת הרוב הדרוש, אך אין בידי ליתן סעד אופרטיבי כלשהו ביחס



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
באר שבע והדרום

לבינוי הקיים כיום. ככל שהתובעים סבורים שמדובר בבינוי חדש שאין לגביו מעשה בית דין מכח פסקי הדין השונים, שמורה להם הזכות לפנות בתביעה מתאימה.

ה. סיכומו של דבר :

86. דין התביעה, בכל הנוגע לדרישת התובעים למתן צו המונע שימוש ייחודי של הנתבע בחצר, ולמתן צו המורה על פתיחת השערים, להידחות, בכפוף לאמור בהסכמות הצדדים שקיבלו תוקף של פסק דין בתיק 95/09. בתוך כך ולמען הסר ספק, מובהר בזאת כי הנתבע אינו נדרש להריסת הגדרות שסובבות את החצר.

87. דינה של התביעה ביחס לבנייה שמבקש הנתבע לבצע בחצר להתקבל, במובן זה שנקבע בזאת שההסכמה למתן זכות לשימוש ייחודית בחצר, לא כללה הסכמה לניצול זכויות בניה, ולפיכך על הנתבע לקבל את הרוב הדרוש בחוק לצורך בנייה בשטח זה, בהתאם, כמובן, לאופי הבנייה המבוקשת. עם זאת, מאחר שלא התבקש סעד של הריסה במסגרת התביעה, ואף לא ברור מה נבנה לאחר הגשת התביעה, איני מורה על סעד אופרטיבי בעניין זה, כמוסבר לעיל.

88. בנסיבות העניין, ובהתחשב בתוצאות ההליך, לא מצאתי לנכון לעשות צו להוצאות.

89. למען הסדר הטוב יוער כי פסק דין זה הינו בין הצדדים לתביעה, ואין בו כדי לחייב בעלי דירות שלא היו צד להליך.

ניתן היום, 09 דצמבר 2013, ו' טבת תשע"ד, בהעדר הצדדים, ונשלח אליהם בדואר רשום עם אישור מסירה.

ש. היילר
מפקח על רישום המקרקעין